



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 147/10

(תביעה שכנגד 147.1/10)

התובע:

רפאל בן - כליפא

ע"י ב"כ עו"ד דוד בן אוליאל

רח' הרב קוק 8, ירושלים

- נ ג ד -

הנתבע:

ניסים ביאזי

ע"י ב"כ עו"ד עוז כהן

רח' בית הדפוס 12, ירושלים

פ ס ק - ד י נ

עניינה של התביעה בדרישת התובע ליתן כנגד הנתבע צו מניעה קבוע האוסר עליו לפלוש לשביל שהינו, כך לטענת התובע, רכוש משותף, וכן אוסר על הנתבע לחסום בפני התובע את הגישה לאורך השביל. מנגד, בתביעה שכנגד שהגיש הנתבע, דרש הנתבע להורות לתובע לפצותו על נזקים שונים שנגרמו לו, להורות על גיזום צמחייה הגולשת משטח התובע לשטחו, ולהשיב את המצב בשטח התובע לקדמותו.

א. העובדות הנדרשות לעניין:

1. המדובר בבית ברחוב יעקב יהושע 69, פסגת זאב, ירושלים, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 30658 חלקה 37, ירושלים (להלן: "הבית"). הבית טרם נרשם כבית משותף, אך אין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה.
2. הבית מורכב מדירת התובע והנתבע, כאשר התובע גר בבית מס' 69 והנתבע בבית מספר 71. ביתו של התובע הינו בסמוך לרחוב יעקב יהושע (להלן: "הרחוב"), וביתו של הנתבע



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

מצוי מזרחית לביתו של התובע. אין חולק כי שני הבתים נמצאים יחדיו על חלקה אחת (להלן גם: "החלקה או המגרש").

3. בצדה הצפונית של החלקה קיים שביל המוביל לדירת התובע והנתבע. על פי המצב נכון להיום, קיימות שתי כניסות מהשביל לשטחו של התובע, האחת, סמוך לרחוב (להלן: "הכניסה הראשונה" - סומנה בספרה "1" במוצג ת/2), והשנייה, סמוכה לקצהו הצפון מזרחי של שטח התובע (להלן: "הכניסה האחורית" - סומנה בספרה "2" במוצג ת/2). השביל ממשיך מזרחה ומגיע לכניסה לשטחו של הנתבע.

4. התובע רכש את ביתו ממר חנניה אלקסלסי (להלן: "אלקסלסי") בהתאם לחוזה המכר - מוצג ת/1. מר אלקסלסי הוא זה שבנה את הכניסה האחורית [ר': עדות הנתבע בעמוד 3 שורות 27-33 בפרוטוקול].

5. בחודש יוני 2010 הציב הנתבע שער ברזל, בסמוך לאחר הכניסה הראשונה של התובע, וחסם את השביל באופן שהתובע לא יכול היה להמשיך לעבור דרכו ולהיכנס לביתו דרך הכניסה האחורית. הנתבע טען, כי שטח זה של השביל הינו בבעלותו מכח הסכמים קודמים עם אלקסלסי, במסגרתם ויתר הנתבע על חניה, ובתמורה קיבל את שטח השביל הנמצא מעבר לכניסה הראשונה של התובע (להלן: "השביל").

6. התובע, אשר לא השלים עם בניית השער כאמור, הסיר את השער, והעבירו לשטח הנתבע.

7. ביום 1.8.10, הגיש התובע תביעה, במסגרתה עתר להורות לנתבע שלא לחסום את הגישה לביתו, להשיב את המצב לקדמותו, ולתקן את הנזקים שנגרמו בשביל ובקירות המהווים, לטענתו, רכוש משותף.

8. הנתבע מצדו הגיש כתב תביעה שכנגד. במסגרת התביעה שכנגד טען הנתבע, כי מאחר והתובע אינו עומד בהסכמים בנוגע לשטח השביל, עליו להשיב לו את החניה שבזמנו נגרעה ממנו. בנוסף דרש הנתבע, כי יינתן צו המורה לתובע לסתום את הכניסה הצפונית לשטחו, מאחר שנבנתה, לטענתו, שלא כדין ונוכח היותה מופנית לשטחו. הנתבע אף טען כי יש לאפשר לו הצבת השער במקום שהוצב, שכן מדובר בשטח שבבעלותו.

9. הנתבע הוסיף וטען, כי כתוצאה משינויים כאלה ואחרים שביצע התובע בשטחו, נגרמו לביתו נזקים רבים, ובכלל זה, זרימת מים לשטחו, ולפיכך דרש הנתבע כי יינתן צו המורה לתובע להשיב המצב לקדמותו. כן דרש הנתבע פיצוי בגין הנזק שגרם לו התובע עת עקר את השער שהציב.

10. לבסוף, טען הנתבע כי צמחיית התובע גולשת לשטחו, ויש להורות על גיזומה באופן שלא תגלוש לשטחו (או לשטח משותף) ולא תסתיר את אור השמש מדירתו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

11. שני הצדדים העידו בפני, ולאחר שכשלו המגעים להביאם לעמק השווה, הוגשו על ידי באי כוחם סיכומים בתביעה ובתביעה שכנגד.

ב. טענות הצדדים בסיכומיהם:

12. התובע מקדים ומבהיר, כי למפקח על רישום המקרקעין סמכות לדון בתובענה בהיותה נוגעת לבית הראוי להירשם כבית משותף, ונוכח העובדה כי עילתה, בין היתר, סילוק יד משטח השייך לתובע ולנתבע גם יחד.

13. לטענת התובע, לנתבע אסור להציב גדר לאחר הכניסה הראשונה, שכן המשך השביל, שהינו, לטענתו, בבעלות משותפת, מוביל גם לכניסה האחורית לשטחו. התובע הבהיר כי למרות היות השביל בבעלות משותפת, אין מניעה מבחינתו להצבת שער לאחר הכניסה האחורית (סומן בספרה "5" בת/2).

14. לטענת התובע, לא הוכח קיומו של הסכם בין הנתבע לבין אלקסלסי במסגרתו הועבר שטח השביל שבמחלוקת לנתבע. לטענת התובע, מאחר שהנתבע טוען לקיומו של הסכם בעל-פה, עליו הנטל להוכחת קיומו, ובמקרה דנן, לא הרים הנתבע נטל זה. בהקשר לכך טוען התובע כי על הנתבע היה לזמן לעדות את אלקסלסי, ומפנה להלכה שלפיה הימנעות צד מהעדת עד שהיה עליו להעידו פועלת לרעתו.

15. לטענת התובע בתיהם של התובע והנתבע, כמו גם השביל, בנויים על חלקה משותפת (בהקשר לכך התובע מפנה לעדות האדריכל מטעמו), וממילא בעלותו של כל אחד מהם מתפשטת בכל אתר ואתר במקרקעין. בהינתן זאת, כך לטענת התובע, חל סעיף 29(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק"), הקובע שהסכם חלוקה יפה כלפי צד ג' רק במידה שהוא נרשם, ומאחר שבענייננו, לא נרשם הסכם חלוקה, הרי שאף אם היה הסכם הוא לא מחייבו.

16. התובע מוסיף וטוען, כי אין כל הגיון בגרסת הנתבע שלפיה הוא רכש את הזכויות בשביל בתמורה לויתור על חלקו בחניה. לטענת התובע, ככל שאכן ויתר הנתבע על החניה, היה זה תמורת קבלת חלק משטח שהיה במקור בבעלות אלקסלסי (שטח אשר סומן בפסים צהובים על גבי נ/3 – להלן: "המגרעת"). עוד מפנה התובע למדידה שהוגשה מטעמו, ושלפיה כיום מחולקים השטחים בין התובע לנתבע, ללא השביל, באופן זהה (293 מ"ר לכל אחד), ולטענתו הדבר מעיד על כי שטח השביל שייך לשניהם גם יחד. התובע מפנה בעניין זה גם לדברי הנתבע עצמו בעדותו שהעיד כי לא היתה הבנה שהוא יקבל יותר שטח משכנו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

17. התובע טוען עוד, כי עדותו של הנתבע התגלתה כלא אמינה, ומפנה בעניין זה לדבריו של הנתבע בעמוד 3 לפרוטוקול. בתוך כך טען התובע כי הנתבע לא דיבר אמת כאשר טען כי הוא שיפץ ובנה את השביל על חשבון.
18. לאור כל האמור, דרש התובע ליתן צו המורה לנתבע שלא לחסום את שביל הגישה לביתו של התובע בכל דרך שהיא, ויאסור עליו להציב שערים או כל דבר דומה, בשביל הגישה עד לאחר הכניסה האחורית של התובע.
19. אשר לנושא הנזקים, הבהיר התובע כי הוא שומר על זכויותיו לתובעם בבית המשפט המוסמך.
20. בסיכומי התובע לתביעה שכנגד נטען על ידו, כי הסרת השער בוצעה כדין, וכי דווקא הצבתו היוותה השגת גבול. התובע מכחיש את טענות הנתבע בעניין נזקים שנגרמו כתוצאה מעקירת השער, ומכל מקום מדגיש כי הדבר אינו בסמכותו העניינית של המפקח.
21. התובע טען כי יש לדחות את טענות הנתבע, שלפיה עבודות שביצע בשטחו גרמו לנתבע נזקים. לטענתו, הנתבע לא הציג ראיות לטענות אלו, ולא עמד בנטל המוטל עליו להוכיחן. התובע אף הפנה לעדות האדריכל מטעמו, שהעיד כי כל הפעולות שביצע היו כדין.
22. התובע הוסיף, כי אף טענת הנתבע בעניין הצמחייה אינה אלא קנטרנית. לטענתו, לו היה הנתבע פונה ומבקש מהתובע לגזום את הצמחייה, תזקה עליו שהוא היה עושה כן, ולא היה כל מקום להגשת התביעה. התובע אף הודיע במסגרת סיכומיו, כי עם היוודע לו במסגרת הדיון, לראשונה, כי הצמחייה מפריעה לנתבע, הוא גזם אותה באופן שלא תגלוש לשטח התובע.
23. לאור כל האמור, דרש התובע כי תביעתו תתקבל, כי תידחה לחלוטין התביעה שכנגד, וכי ייפסקו לטובתו הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד כדין.
24. מן העבר השני טען הנתבע כי יש לדחות התביעה ולקבל את התביעה שכנגד.
25. תחילה, ביקש הנתבע למחוק את כל הסעדים הנזיקיים מתביעתו, תוך שהוא ביקש לשמור את זכותו להיפרע בגין נזקיו, באמצעות הגשת תביעה לערכאה המוסמכת.
26. לגופו של עניין טען הנתבע, כי הוא בעל הזכויות בשטח השביל לאור הסכם שנכרת בינו לבין אלקסלסי. לטענתו, במסגרת ההסכם הוא ויתר על חניה שהיתה לו בפינה המערבית של החלקה, סמוך לרחוב הראשי, כפי שמופיע בהיתר המקורי – מוצג נ/3, בתמורה לקבלת חזקה ייחודית בשטח השביל שבמחלוקת. הנתבע אף טען, כי בעקבות ההסכם



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

הנ"ל הוא שיפץ על חשבונו את השביל, ובנה מדרכת אבן, קירות ומדרגות, בעלות כספית גבוהה.

27. הנתבע טען, כי עדותו בדבר קיומו של הסכם לא נסתרה, וכי ממילא אין משמעות לעדות התובע בעניין זה בהיותה עדות שמיעה בלבד. כן טען הנתבע כי הנטל להוכחת התביעה מוטל על התובע, וכי החובה עליו להעיד את מר אלקסלסי. משלא עשה כן התובע, משמש הדבר לחובתו. הנתבע אף טען כי התנהלות התובע עולה כדי "הודאה והדחה" שכן הוא לא שלל את האפשרות לקיום הסכם בעל פה. בעניין זה הוסיף הנתבע וטען כי אין לשעות לטענות התובע כי ההסכם היה "חניה תמורת מגרעת", שכן להוכחת טענה זו היה על התובע להביא לדיון את מר אלקסלסי. הוסיף הנתבע וטען, כי מדובר במצב ששרר בבית שנים רבות ללא שמישהו חלק על כך.

28. הנתבע טען עוד, כי ההסכם שנכרת בינו לבין אלקסלסי, מחייב גם את התובע למרות שהוא לא נרשם, זאת מכח הסכמה ונוהג מושרש. הנתבע מפנה בעניין זה לע"א (חי) 1020/03 **בובליל ישראל נ' שטיינר יוסף** (פורסם באתר נבו), לתיק מפקחת (חי) **אלקין נ' אונגר**, תיק מפקח (י-ם) **עטרי נ' אלטרץ**, ולתיק מפקחת (בי"ש) **זכריה נ' נזהד** (אתר משרד המשפטים).

29. לחילופין, טען הנתבע, כי הצבת השער תוך מסירת מפתח לתובע מהווה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף, שאינו דורש הסכמת התובע.

30. הנתבע טען, כי התביעה אינה אלה "הקדמת תרופה למכה" המוגשת בחוסר תום לב מוחלט, וזאת נוכח חששו של התובע מכך שהוא ייתבע על גרימת נזקים לנתבע. הנתבע טען אף להטעיות רבות בסיכומי התובע.

31. אשר לתביעה שכנגד – לטענת הנתבע, התובע מגדל בשטחו צמחיה, שעליה ופירותיה נושרים לשטחו של הנתבע, לשטח השביל, ומהווים סכנה ומטרד חמורים. כן טוען הנתבע כי הצמחיה ששתל התובע, המתנשאת לגובה של כשני מטרים מסתירה לתובע את הנוף, ומונעת כניסת אוויר לביתו. לטענת הנתבע בכך מפר התובע את הוראות התקנון המצוי, שכן בפעולותיו ומחדליו הוא גורם נזק לדירה אחרת. התובע דרש, על כן, כי יינתן צו עשה המורה לתובע לקצוץ את הצמחיה באופן שלא תסתיר את אור השמש, ולהורות לו לטפל בצמחיה לבל תגרום למפגע בשטח הנתבע ובשביל.

32. הנתבע טען עוד, כי התובע הגביה את הריצוף בשטחו ויצר מצב בו מי הגשמים ניגרים לשטח הנתבע. על כן, דרש הנתבע כי יינתן צו המורה לתובע להשיב הריצוף לגובהו המקורי.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

33. הוסיף וטען הנתבע, כי יש להשיב המצב לקדמותו באופן שהחניה המסומנת בהיתר הבניה המקורי [מוצג נ/3] כחניתו של ביאזי, תושב לידיו.
34. לאור כל האמור, דרש הנתבע לדחות את התביעה העיקרית, לקבל את התביעה שכנגד, ולחייב את התובע בהוצאות משפט ושכ"ט כדין.

ג. דיון הכרעה:

35. ראשית יוער, כי מרבית מעילות התביעה שבתביעות ההדדיות, אכן מצויות בסמכות המפקח על רישום המקרקעין.
36. בתביעה העיקרית טוען למעשה התובע לסילוק יד הנתבע משטח המהווה, לטענתו, שטח משותף, וברי, כי נושא זה חוסה תחת סמכות המפקח, בהתאם לסעיף 72(ב) לחוק. אמנם, כדי להכריע בשאלת הסגת הגבול יהא עלי להידרש לטענות הצדדים ביחס לזכויות שונות ברכוש המשותף, ואולם מדובר בסוגיה שבסמכותו הנגררת של המפקח [ר' למשל: רע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, פורסם באתר נבו].
37. גם הסעד העיקרי שבתביעה שכנגד, היינו מניעת היזק מצד בעל דירה אחת לבעל דירה אחרת, מצוי בסמכות המפקח, וזאת בהתאם לסעיף 72(א) לחוק, ונוכח סעיפים 2-3 לתקנון המצוי החל בענייננו.
38. עם זאת, כפי שאף הבהירו הצדדים בסיכומיהם, כל הטענות שעניינן פיצוי בגין עוולות נזיקיות כאלה ואחרות, אינן בסמכותו העניינית של המפקח [ר' למשל: ד.ג. 20/73 שמע נ' סדובסקי ואח' פד"י כ"ח (1) עמ' 730; ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130; ע"א 458/69 שליט נ' גולדברג פד"י כ"ד(1) 231]. משכך, ועל פי הודעות הצדדים ובקשתם, אני מוחק סעדים אלו מהתובענות, ושמורה לצדדים הזכות לתובעם בבית המשפט המוסמך. דומה, כי גם הסעד החלופי הנטען על ידי הנתבע בתביעה שכנגד, לביטול ההסכם הנטען על ידו והשבת החניה לידיו, אינה חוסה תחת סמכותו העניינית של המפקח, כפי שיובהר להלן.
39. **לגופו של עניין – התביעה העיקרית:**
40. שורש מחלוקתם של הצדדים הינה בשאלה, האם היה הסכם כלשהו בין הנתבע לאלקסלסי שקבע כי הבעלות בשביל תועבר לנתבע תמורת ויתורו על חניה, וככל שהיה הסכם כזה, האם הוא מחייב את התובע.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

41. שאלת קיומו של ההסכם, לא הובררה עד תום בדיון שנערך בפני. מצד אחד, אכן צודק הנתבע כי העדות היחידה ביחס להסכם הנטען, שאינה עדות שמיעה, אינה אלא עדותו, ולפיה היה הסכם בינו לבין מר אלקסלסי, במסגרתו וויתר הנתבע על חניה תמורת בעלות בשביל. צודק גם הנתבע בטענתו, כי מאחר שנטל ההוכחה מוטל על התובע, היה עליו להזמין את מר אלקסלסי לעדות, כדי להפריך טענה זו של הנתבע. זאת ועוד, ממילא נכון היה שהתובע יזמין את מר אלקסלסי כעד מטעמו, לאור המחויבות של מר אלקסלסי כלפיו נוכח הוראות הסכם המכר שנכרת ביניהם [ר' מוצג ת/1]. מנגד, גרסתו של הנתבע שלפיה הוא ויתר על חניה תמורת שביל אינה סבירה, ודווקא מסקנתו של התובע שלפיה ויתור הנתבע על החניה היה תמורת ה"מגרעת" עולה בקנה אחד עם השכל הישר. עמדת התובע אף עולה בקנה אחד עם העובדה שכיום, ללא השביל, חלוקת השטחים בין הצדדים שווה [ר' מוצג ת/2 אשר לא נסתר על ידי הנתבע]. יתרה מכך, גרסתו של הנתבע הינה גרסת בעל דין אשר לא נתמכה בראיה כלשהי מעבר לעדותו שלו, והיא אף לקתה באי בהירות, ולעיתים גם אי דיוקים [ר' למשל עדותו בעניין פריצת הכניסה האחורית – עמוד 3 לפרוטוקול שורות 28-34].
42. לצורך הדיון, מבלי כמובן לקבוע מסמרות ומבלי להכריע בשאלה, מוכן אני לצאת מנקודת הנחה כי היה הסכם כלשהו בין מר אלקסלסי לבין הנתבע, שכן לדידי, אף אם היה הסכם כזה, הוא אינו מחייב ביחסים שבין התובע לנתבע.
43. כמובא לעיל, אחת המחלוקות הבסיסיות שבין הצדדים הינה בשאלה האם ההסכם שבין ביאזי לאלקסלסי חייב היה להירשם כדי לחייב צדדים שלישיים. בתוך כך, חלוקים הצדדים גם בשאלת תחולת סעיף 29(א) לחוק, הקובע כי "הסכם בין השותפים... ניתן לרישום, ומשנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן...", על ענייננו.
44. המדובר, כזכור, בבית שאינו רשום עדיין כבית משותף, וממילא חלות על ענייננו הוראות פרק ו' לחוק. סעיף 277 לחוק קובע כי: "סעיפים 56, 57, 58, 59, 59א עד 62(א), 65, 68 עד 70, 71, 71א עד 71ד, ו-72 עד 77 יחולו על בית לפי פרק זה, בשינויים המחויבים".
45. לכאורה, בהינתן זאת, ונוכח הוראות סעיף 56 לחוק הקובע כי "הוראות פרק ה' לא יחולו על הרכוש המשותף", צודק הנתבע בטענתו כי סעיף 29 לחוק, ובכלל זה סעיף 29(א) לחוק, שלפיו הסכם בין שותפים מחייב את הבאים בנעלי המתחייב, רק עם רישומו, אינו רלוונטי לענייננו.
46. אולם, כבר נקבע כי הוראות פרק ו' לחוק נועדו להסדיר את אופן ניהולו של הבית המשותף, ולא את זכויותיהם הקנייניות של בעלי הזכויות [ר' : רע"א 698/85 יהודה בן



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- צור נ' נעים ששון**, פ"ד, מא(3), 144; ר' גם י. ויסמן, דיני קניין (בעלות ושיתוף), 523. בכל הנוגע לבחינת הזכויות הקנייניות של בעלי הדירות, עלינו לבחון אפוא את הדברים על פי הוראות החוק הרלוונטיות למקרקעין שבבעלות משותפת, ובכלל זה סעיף 29 לחוק. יוער, כי ממילא, בהיעדר הוראה ספציפית לעניין, יש מקום ל"החלה היקשית" של דיני השיתוף הכלליים על הרכוש המשותף בבית משותף [ר': מ. דויטש, קניין, א, 707].
47. על כן, מקובלת עלי העמדה העקרונית, כי במקרה דנן, קרי, בבית שאינו רשום כבית משותף, יש מקום להחלת העקרונות הקבועים בסעיף 29(א) לחוק, שלפיהם כוחו של הסכם יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן, בכפוף לרישום.
48. ודוק: לאותה תוצאה שלפיה רק הסכם שנרשם מחייב צדדים שלישיים, ניתן להגיע אף מכח הוראות סעיף 77א' לחוק, וכן סעיף 1 לתקנון המצוי, החל על בתים הראויים להירשם כבית משותף מכח סעיף 77 לחוק.
49. על פי סעיפים אלו, חלקי הבית המיועדים לשמש את כלל בעלי הדירות מהווים "רכוש משותף". הלכה היא, כי הגדרה זו נבחנת לפי "מבחן הייעוד", וכי ככל שמדובר בשטח שאמור לשרת את הצדדים בצוותא, אין אחד רשאי להגביל את זכות השימוש של חברו ללא הסכמתו [ר' עניין בן צור הנ"ל]. בנוסף, בהיות חלק מסוים עונה על הגדרת "רכוש משותף" כאמור, החלטה בנוגע לאופן השימוש בו תחייב צדדים שלישיים רק אם היא נרשמה כמקובל, זאת מכח סעיף 71 לחוק החל גם על בית שאינו רשום כבית משותף, אך לא תחייב אם היא לא נרשמה [ר': י. ויסמן, שם, 526; א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, 289].
50. הנה כי כן, כך או כך, סבורני כי, ככלל, הסכם בין בעלי דירות בבית שאינו רשום כבית משותף, בדבר שימוש ייחודי בשטח שעל פי ייעוד המקורי הינו משותף, אמור להירשם כדי לחייב צדדים שלישיים.
51. עם זאת, ההלכה הפסוקה ריככה את דרישת רישומו של ההסכם כתנאי לתוקפו כלפי צדדים שלישיים. לא פעם נקבע, כי במקרה בו גלוי וידוע לצדדים דבר קיומו של ההסכם, ורישומיו נכרו עקב הבינוי והנוהג בשטח מזה עשרות בשנים, יחייב ההסכם, אף אם לא נרשם, גם כלפי צד ג' [ר' למשל פסק הדין המובא בסיכומי הנתבע: ע"א (חי) 1020/03 **בובליל נ' שטיינר** (פורסם באתר נבו); מ. דויטש, שם, 734]. כן רוככה דרישת רישום ההסכם, תוך מתן אפשרות לבית המשפט להכפיף את זכות הקניין של הבעלים להשתמש בזכותו בתום לב [ר': רע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פד"י נה(1), 199].
52. בכל מקרה ומקרה, עלינו לבחון אפוא גם את ידיעתו של הצד השלישי ואת תום ליבו.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

53. מן הכלל אל הפרט: במקרה דנן, הוכח בפני באופן חד משמעי כי התובע לא ידע ולא יכול היה לדעת כי היה הסכם.
54. לית מאן דפליג, כי מלכתחילה היה שטח השביל שבמחלוקת בבעלות משותפת, והוא אמור היה לשרת את שני הצדדים [שהרי גם לשיטת הנתבע מדובר בהסכם שנכרת בינו לבין אלקסלסי לאחר רכישת הקרקע].
55. כן עולה מעדות הצדדים, כי עת רכש התובע את ביתו, הכניסה האחורית היתה קיימת בשטח, ולא היה כל שער או חסימה אחרת בשביל המוביל אליה [ר' עדות גב' בן כליפא בעמוד 2 לפרוטוקול; עדות מר אסתרקינד בעמוד 4 לפרוטוקול; עדות התובע בעמוד 7 לפרוטוקול; עדות הנתבע בעמוד 2 ו-3 לפרוטוקול].
56. שוכנעתי גם כי אופיו של האזור ומיקומו, כמו גם העובדה כי הנתבע לא חלק על כך שכל השנים עשה מר אלקסלסי שימוש בשביל [ר' עדות הנתבע בעמוד 3 לפרוטוקול], יצרו אצל התובע את הרושם כי מדובר בשטח משותף.
57. מכלול עובדות וראיות אלו, מביאות למסקנה כי התובע לא ידע ואף לא יכול היה לדעת על ההסכמה הנטענת, ובוודאי שלא יכול היה התובע ללמוד כי קיים הסדר כלשהו המגביל את זכותו בשביל הקיים. להיפך.
58. אף לא מצאתי בדרישת התובע ולו בדל של חוסר תום לב, שהרי השביל סמוך לשטחו ודרכו הוא נכנס לשטח האחורי של ביתו.
59. בהינתן זאת, אין לי אלא לקבל את טענת התובע, כי אף אם היתה הסכמה כזו או אחרת היא לא מחייבת את התובע.
60. לפיכך, דינה של התביעה העיקרית להתקבל אפוא, במובן זה שניתן כנגד הנתבע צו המורה לו לסלק ולהסיר כל שער ו/או מכשול החוסם את המעבר בשביל, ולאפשר לתובע כניסה חופשית לכניסותיו (הן הראשונה והן האחורית).
61. אין בידי לקבל גם את טענת הנתבע החלופית בסיכומיו, שלפיה יש להתיר לו הצבת שער בכפוף למסירת מפתח. הצבת השער, מספחת הלכה למעשה את השטח לנתבע, ולא ניתן לראות בהצבתו, גם אם ימסור הנתבע מפתח לתובע, שימוש רגיל וסביר.
62. **התביעה שכנגד:**
63. בתביעה שכנגד טען הנתבע לכך שכתוצאה משינויים כאלה ואחרים שעשה התובע בשטחו, נגרמו לו נזקים בביתו. טענות אלו לא הוכחו, וממילא אין מקום להורות על השבת המצב לקדמותו. עם זאת, למותר לציין, כי בהתאם לסעיפים 2-3 לתקנון המצוי, החל בענייננו,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

חובה על התובע לדאוג לתקינות דירתו ומתקניו, לבל ייגרם נזק לביתו של הנתבע. על התובע לוודא כי אכן אין במעשיו או מחדליו, ואו בהגבהת שטחו כדי לגרום נזק לנתבע, ולתקן את כל הדרוש תיקון לשם כך.

64. אשר לצמחיה - כפי שעולה מעדות הנתבע, אשר לא נסתרה, התובע שתל שיחי פסיפלורה, אשר פירותיהם ועליהם נושרים לדירת הנתבע ולשביל. כן עולה מעדות הנתבע אשר לא נסתרה, כי שיחים אלו (נכון למועד הגשת התביעה) גבהו מעבר לגדר הקיימת והגיעו לגובה של כשני מטרים, הסתירו חלק מחלונותיו של הנתבע, ומנעו ממנו אור ואוויר.

65. כאמור לעיל, בהתאם לתקנון המצוי, על בעל דירה לדאוג לכך שלא ייגרם נזק מדירתו לדירה אחרת, וחובה עליו לבצע כל תיקון בדירתו שאי ביצעו עלול להזיק לדירה אחרת או להפחית מערכה.

66. לפיכך, אני מקבל את תביעת הנתבע להורות לתובע לקוץ את הצמחייה, באופן שגובהה לא יעלה על מעבר לתחתית חלונות הנתבע בקומה השנייה, אשר הוסתרו על ידי הצמחייה שגבהה כאמור. כן אני מורה לתובע לדאוג לכך שלא ינשרו עלים, פירות וכד', לשטחו של הנתבע, וכן לדאוג באופן קבוע לניקיונו של השביל.

67. טענה אחרונה של הנתבע הינה כי יש להשיב המצב לקדמותו באופן שהחניה המסומנת בהיתר הבניה המקורי [מוצג 3/3] תושב אליו. כאמור, טענתו של הנתבע בעניין זה היא כי שטח זה הוקנה לתובע במסגרת אותו הסכם עם אלקסלסי, אלא שיש לבטל ההסכם ולהשיב החניה לבעלותו, מפאת אי עמידת התובע, כך לטענתו, בהסכם, בכך שהוא לא מקנה לו זכות בשביל.

68. אין בידי להיעתר לסעד מבוקש זה. ראשית, סעד זה אינו בסמכות המפקח על רישום המקרקעין, שכן אין מדובר בדרישה לסילוק יד, כי אם בדרישה לביטול הסכם והשבה, תוך קביעת בעלות. שנית, אף לגופו של עניין לא מצאתי ממש בטענה, שכן, כאמור, הסכם זה לא מחייב את התובע. מכל מקום, אף לא הוכח בפני קיומו של הסכם כזה ברמת ההוכחה הנדרשת כדי לבסס עילת תביעה זו של הנתבע (ודוק: הנחת המוצא כי קיים הסכם היתה לצורך הדיון בטענת ההגנה של הנתבע בלבד).

ד. סוף דבר:

69. אני מורה לנתבע שלא להציב שער החוסם את השביל ואת המעבר לכניסותיו של התובע.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

70. אני מורה לתובע לקוץ את הצמחייה בשטחו, באופן שלא תסתיר את חלונות הנתבע כאמור, ולא תהווה פגיעה בשטחו או בשטח השביל כאמור.

71. שקלתי רבות האם נכון לעשות צו להוצאות כנגד מי מהצדדים במקרה דנן. בסופו של דבר, נוכח תוצאת הדברים, ולאור העובדה שבשלב מסוים עמד התובע על ניהול ההליך כולו ולא נאות לניסיון הנתבע להגיע לפשרה שהיה בה כדי לחסוך מהצדדים ומהמפקח משאבים רבים, החלטתי שכל צד יישא בהוצאותיו.

ניתנה היום, כ"ח אב תשע"א (28 אוגוסט 2011) בהעדר הצדדים, ונשלח אליהם בדואר רשום עם אישור מסירה.

ש. הייזלר
מפקח על רישום המקרקעין